

1065134-94.2020.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Anulação

Magistrado: SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 9ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... NETO), que possui ficha criminal por tráfico de drogas e roubos; e, em razão deste fatos, a Comissão do Concurso motivou a reprovação com base nos itens 6.13 e 6.18.

É certo que o ato impugnado consiste em discricionariiedade da Administração, estando, portanto, condicionado à conveniência e necessidade do interesse público. Entretanto, mesmo os atos discricionários podem ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

9ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1065134-94.2020.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1065134-94.2020.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Anulação

Requerente:

Kevin Richard Ferreira Rola

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI

Vistos.

KEVIN RICHARD FERREIRA ROLA, qualificado nos autos, moveu ação pelo procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (FESP), alegando, em síntese, ter participado de concurso público para o cargo Soldado da Polícia Militar (edital nº 002/321/19) e, ultrapassadas a fases iniciais, foi reprovado na investigação social. Sustentou que o ato administrativo que determinou sua exclusão do certame não foi devidamente motivado pela Comissão de Concurso Público. Concluiu pela violação aos princípios da publicidade, motivação e razoabilidade. Destacou a configuração de dano moral, o que enseja o direito de reparação a ser subsidiado pelo Estado nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Requereu a concessão da tutela provisória para assegurar a reintegração ao certame, com a participação nas etapas subsequentes; e, ao final, a procedência da ação para (1) reconhecer a nulidade do ato administrativo de reprovação, considerando a data da exclusão para fins de promoções na Polícia Militar, e (2) condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais. Atribuiu à causa o valor de R\$ 75.000,00.

Com a inicial vieram documentos (fls. 07/79).

Deferida a gratuidade processual e a tutela postulada (fl. 81).

Regularmente citada pelo portal eletrônico (fls. 82/84 e 87/88), a FAZENDA ingressou no feito e ofertou contestação (fls. 90/114), acompanhada de documentos. No mérito discorreu sobre a finalidade da etapa de investigação social no certame concorrido e defendeu a legalidade do ato administrativo atacado, tendo em vista que a inaptidão do candidato se deu pela incompatibilidade de perfil exigido para o ingresso na Corporação. Apontou não ser de competência do Poder Judiciário a análise dos critérios de conveniência e oportunidade dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes (artigo 2º da Constituição Federal). Por fim, fundamentou a inexistência de dano, porque o ato impugnado afigura-se legal, o que implica a impossibilidade de acolhimento da pretensão indenizatória. Concluiu pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Sobreveio réplica (fls. 215/229).

Determinada a manifestação quanto à necessidade de dilação probatória (fl. 247), o autor pugnou pelo julgamento do processo (fl. 252) e a ré, embora intimada (fls. 248 e 251), permaneceu inerte conforme certidão à fl. 255.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O julgamento antecipado é medida que se impõe, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, porque a questão de mérito é de direito e fato e são suficientes os documentos anexados aos autos.

Em resumo, pretende o autor a nulidade do ato administrativo que implicou sua reprovação em concurso público para o cargo de SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR na fase de "investigação social" e, em consequência, (1) a reintegração ao certame, assegurando a participação nas etapas subsequentes, e (2) a definição da data da exclusão como termo inicial para fins de promoções na Corporação; bem como a condenação em pagamento de indenização por danos morais.

Inexistindo preliminares, ao mérito.

A contratação de servidores, em regra, ocorre mediante concurso público de provas ou provas e títulos, no qual a Administração, de acordo com o disposto na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, oferece igual oportunidade aos candidatos, selecionando-se aqueles que preencherem os requisitos e forem qualificados.

No entanto, cada concurso público deve prever as peculiaridades da seleção que se deseja realizar e a Administração possui discricionariedade para estabelecer as regras e critérios de julgamento do certame, respeitada a legislação e, principalmente o princípio da isonomia.

Assim, todo o regramento do concurso público deve constar no edital, ao qual devem submeter-se todos aqueles que participem do processo seletivo, motivo pelo qual se diz que o edital é "a lei do concurso".

Destaque-se que, pelas características do cargo em concurso, plenamente justificada a necessidade de investigação social, para seleção dos candidatos mais adequados à função que será exercida.

Aliás, a fase de investigação social está em conformidade com o artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal, bem como em consonância com a legislação pertinente (Lei Complementar nº 697/92, regulamentada pelos Decretos nº 41.113/96 e nº 42.053/97).

De acordo com as informações prestadas pela Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, a etapa de Investigação Social (IS) tem por objetivo averiguar a idoneidade dos candidatos, mediante identificação de eventuais condutas inadequadas, cuja gravidade poderá implicar exclusão do certame.

Além disso, o fornecimento incorreto de informações ou a omissão de dados relevantes é considerado como comportamento incompatível com a função de policial-militar, bem como tentativa de ludibriar a administração do concurso.

No caso vertente, com auxílio das informações às fls. 115/170 foi possível identificar os reais motivos que alicerçaram a reprovação do autor na etapa de investigação social, uma vez que a contestação foi apresentada de forma genérica, limitada a ressaltar a legislação pertinente ao certame.

Segundo o Chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar (CIPM), a inaptidão teve por fundamento "condutas desabonadoras", contrárias às exigidas para o

ingresso da Corporação, em especial, as relacionadas nos itens 6.13 "pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminoso ou que possam induzir ao cometimento de crimes"; 6.15 "possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra a moral e os bons costumes"; 6.18 "possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo" e 6.32 "pessoa que apresente dados com inexatidão, omita dados relevantes, declare informações inverídicas ou revele desídia no preenchimento do Formulário desta etapa".

No curso da pesquisa social, segundo a autoridade, foram constatados (1) a convivência da genitora do autor (ILANA FERREIRA ROLA) com "indivíduos de péssima índole, que são conhecidos na localidade como pessoas que traficam substâncias entorpecentes ilícitas - drogas", (2) a existência de registros policiais e criminais, nos quais se incluem os delitos de ameaça, roubo e lesão corporal, em desfavor de seu genitor, e (3) o estreito contato pessoal com primo (JORGE FERREIRA ROLA NETO), que possui ficha criminal por tráfico de drogas e roubos; e, em razão deste fatos, a Comissão do Concurso motivou a reprovação com base nos itens 6.13 e 6.18.

É certo que o ato impugnado consiste em discricionariedade da Administração, estando, portanto, condicionado à conveniência e necessidade do interesse público. Entretanto, mesmo os atos discricionários podem ser submetidos à análise do Poder Judiciário, não só no que diz respeito aos aspectos formais, mas também em relação à finalidade e conteúdo, considerando os princípios que está sujeita a Administração Pública, dentre eles a razoabilidade e a proporcionalidade. Ocorre que, neste tópico, o ato, apesar de discricionário e expressamente previsto do edital do certame, violou o princípio da razoabilidade, isto porque, não pode o autor ser penalizado por condutas, atos infracionais e crimes praticados por terceiros, sob pena de ofensa ao princípio da intranscendência da pena, contemplado expressamente no artigo 5º, inciso XLV da Constituição Federal, que, embora seja correntemente aplicado na esfera penal, pode ser empregado, ainda que indiretamente, na esfera administrativa.

No mais, possível inferir que o candidato não omitiu as informações relativas a JORGE FERREIRA ROLA NETO (primo), seja quanto aos antecedentes criminais seja quanto uso de substâncias entorpecentes, tanto que as detalhou no Formulário de Investigação Social (FIS), nas questões 31 e 32.

Deve ser reconhecida, por consequência, a honestidade do candidato.

Desse modo, a conduta que fundamentou a exclusão do candidato no certame, diretamente relacionada a terceira pessoa, não é hábil para considerá-lo um desajustado social e incapaz de exercer as funções de um policial militar; não sendo, portanto suficiente para embaraçar a reputação ilibada do autor.

Quanto ao emprego do item 6.32 do Capítulo XII do edital para apoiar a desqualificação, pela suposta omissão a respeito (1) do relacionamento com a genitora de sua filha e (2) de dados do proprietário de motocicleta que detém a posse (fl. 141), razão não assiste à ré, pois, em nenhum momento, faltou com a verdade; pelo contrário, registrou tais fatos nas questões nºs 19, 20 e 60, nos exatos moldes do Formulário.

A inexistência de detalhamento de elementos envolvendo à mãe de sua filha decorre da própria ausência de relacionamento público e duradouro formalizado por casamento ou união estável, como aclarado à fl. 221.

Mais precisamente com referência à descrição de informações do suposto padrasto/namorado de ILANA FERREIRA ROLA, não foi cabalmente comprovada a conduta dolosa do candidato.

Além disso, o edital do certame prevê como hipótese de reprovação na etapa de investigação social a omissão de DADOS RELEVANTES, e, desta forma, entendo que, no caso concreto, a indicação de residência e ocupação profissional do padrasto/namorado de ILANA FERREIRA ROLA não se afigura significativa para conduzir à eliminação do candidato.

Finalmente, no que concerne ao item 6.15 ("possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra a moral e os bons costumes"), caracterizado por apresentar

"corriqueiramente comportamentos pessoais hostis e desrespeitosos quando avista viaturas da Polícia Militar que realizavam o patrulhamento nas imediações" e "proferia palavras de calão em desfavor das equipes policiais, fato que ocasionava abordagens à sua pessoa", sem razão a ré, pois não há qualquer documento escrito que comprove a existência de tal oitiva, a identificação dos vizinhos contatados, o ano/frequência das ocorrências, dentre outros. E, embora intimada para a indicação de provas, a Fazenda deixou transcorrer o prazo in albis.

Agiu com desacerto a Administração Pública, com rigor excessivo e em descompasso com a realidade, pois deve-se fazer uma análise da situação social atual e reanalisar, de fato, quais os candidatos que apresentam o perfil do policial militar.

Tecidas tais observações, o ato administrativo merece reparo pelo Judiciário, ante a violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema, destaca-se o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que se coaduna com o entendimento adotado por esta Juíza:

APELAÇÃO - CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR 2ª CLASSE - EDITAL DP 3/321/19 - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - INAPTIDÃO Recurso genérico de apelação - Ausência de impugnação dos fundamentos da sentença - Inadmissibilidade - Princípio da dialeticidade recursal que impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida - Recuso voluntário de apelação não conhecido. REEXAME NECESSÁRIO - Considera-se interposto o reexame necessário porque o benefício almejado não tem valor econômico certo - Aplicação do art. 496 do Código de Processo Civil - Candidata reprovada em investigação social por ter sido apurado histórico de relações com pessoas envolvidas com práticas delituosas (irmãos) - Condutas desabonadoras de terceiros não implica na desclassificação da candidata - Cartas de recomendação e declarações escolares que demonstram que a candidata possui perfil compatível com o cargo almejado - Sentença de parcial procedência mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO, REMESSA NECESSÁRIA, CONSIDERADA INTERPOSTA, NÃO PROVIDA. (TJSP; Apelação Cível 1042571-72.2021.8.26.0053; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/03/2022; Data de Registro: 08/03/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONCURSO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - Soldado PM 2ª Classe (Edital nº DP-3/321/19) - Pretensão de anular a decisão que reprovou o candidato na fase de Investigação Social - Suposta convivência com pessoas envolvidas em práticas delituosas, problemas disciplinares na escola e omissão no preenchimento de informação no Formulário da Investigação Social - Ausência de comprovação de que o candidato resida com o irmão ou conviva com o tio - Alegação de problemas disciplinares que é genérica e não é confirmada pelo histórico escolar do candidato - Não comprovação de que a omissão no formulário foi dolosa - Ausentes a razoabilidade e a proporcionalidade do ato administrativo - Cabimento da reinserção ao certame - Inexistência de dano moral - Sucumbência recíproca - Sentença de improcedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1043677-69.2021.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/02/2022; Data de Registro: 23/02/2022)

RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO DE 2ª CLASSE. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. Pretensão voltada à reintegração de candidato ao certame para provimento de cargo de soldado de 2ª classe da Polícia Militar. Sentença de procedência na origem. Inconformismo de ambas as partes. Mérito. Candidato excluído do certame, na fase de investigação social, por duas omissões no formulário de investigação social. Omissões irrelevantes que não influenciam na conduta social, reputação e idoneidade do candidato. Boletins de ocorrência da sua ex-cônjuge que versam sobre descumprimento de guarda compartilhada de filho gerado com terceiro. Situação que não conduz à conclusão de

incompatibilidade da personalidade do autor para o cargo almejado. Interpretação extensiva dada da Administração que não se admite, porquanto despida de elementos probatórios. Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ilegalidade da limitação posta ao direito do autor. Controle jurisdicional para afastar o ato de exclusão do candidato, reintegrando-o ao certame. Honorários advocatícios. O valor da verba honorária fixado em primeiro grau é ínfimo, comportando majoração. Fixação por equidade no valor de R\$ 2.000,00, já considerada a sucumbência recursal prevista no art. 85, §11º do CPC. Sentença reformada apenas para majoração dos honorários advocatícios. Recurso do autor parcialmente provido e recurso oficial e da FESP desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1043963-47.2021.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Apelação - Nulidade de ato administrativo - Candidato excluído do concurso para provimento de cargos de Soldado PM na fase de investigação social - Sentença de parcial procedência - Remessa necessária e recurso voluntário do Estado de São Paulo - Desprovidimento de rigor - Ausência de omissão no preenchimento de formulário de avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade - Fatos apurados pela investigação ligados a terceiros e que não servem para reprovar o candidato no certame - Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Precedentes deste E. TJSP - R. sentença mantida - Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1065546-25.2020.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022)

Descabida, contudo, a retroação da data da exclusão como termo inicial para fins de promoções na Corporação, pela ausência do efetivo exercício do cargo e de adequação aos critérios estabelecidos pela lei complementar nº 1.224/13.

No que diz respeito aos danos morais, o pedido é improcedente.

Tem-se entendido que o dano moral consiste em lesão a direito da personalidade e não decorre do mero descumprimento contratual ou legal.

Na lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Programa de Responsabilidade Civil, 2a edição, pág. 78, Malheiros Editores).

Afasta-se, então, o dano moral porque a situação vivenciada pelo autor não passa de mero aborrecimento, sem causar vexame ou constrangimento.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a ação e EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade do ato administrativo de reprovação do autor do concurso público de Soldado da Polícia Militar (edital nº 002/321/19), na fase de investigação social, e garantir sua reintegração e participação nas etapas subsequentes.

Sucumbência recíproca, as partes arcarão com honorários advocatícios (artigo 85, parágrafo 14 do Código de Processo Civil) , que fixo em 10% do valor da condenação, e as custas serão divididas meio a meio.

Tendo em vista que o demandante é beneficiário da gratuidade processual, está suspenso o pagamento das verbas de sucumbência.

P.R.I.

São Paulo, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA